



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 482/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: דליה חלוץ
ע"י ב"כ עוה"ד ניר אורן
מרחוב כצנלסון 70 גבעתיים

נ ג ד

הנתבעת: מזל מסורי
מרחוב הגלבוש 15 גבעתיים

פסק דין

האם בידי הנתבעת רשות כדין לעשות שימוש ייחודי בחצר המהווה רכוש משותף בבית ברחוב גלבוש 15 גבעתיים, ואם כן מה טיבה של אותה רשות. זו, בתמצית, השאלה שבמחלוקת בהליך זה.

מוסכמות, טענות הצדדים ונקודת המחלוקת

1. הצדדים הינם שניים מבין בעלי הדירות בבית שברחוב גלבוש 15 גבעתיים הבנוי על חלקה 376 בגוש 6160.

2. הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם. בבית 4 דירות - שתיים בקומת הקרקע ושתיים בקומה הראשונה. דירת התובעת ממוקמת בקומה הראשונה בעורף הבית כאשר דירת הנתבעת ממוקמת בקומת הקרקע בחזית הבית.

3. בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף לכל דירה בבית רבע מהזכויות ברכוש המשותף כאשר לא הוצמדו כל חלקים מהרכוש המשותף לאיזה מהדירות ולא הוקנו זכויות שימוש ייחודיות. התקנון המוסכם מקנה זכות לבעלי הדירות להוסיף בניה לדירות הקיימות בכפוף לקבלת היתרי בניה ותנאים נוספים.

4. התובעת טוענת כי הנתבעת סיפחה לדירתה חלק ניכר מהחצר בחזית הבית - היא עושה שימוש בלעדי ללא רשות בכל החצר המערבית בחזית, לרבות ריצוף החצר, היא מניחה מטלטלין ואופנוע בחצר, היא בנתה קיר אבנים וגדר עץ ומונעת את הגישה והשימוש מבעלי הדירות האחרים. בנוסף ביצעה הנתבעת בניה בלתי חוקית בחצר - היא בנתה חדר כביסה בחצר הדרום מערבית, מחסן בחלק הצפון מערבי והציבה שער כניסה לדירתה מהחצר. לאחר מו"מ שהתנהל בין הצדדים הוסכם כי לכל הסדר שיוסכם עם בעלי הדירות האחרים בבית (אשר גם הם עושים שימוש ייחודי ברכוש המשותף) תצטרף גם הנתבעת. בהתאם הגישה התובעת תביעה כנגד בעלי דירות אחרים בבית (מבלי לתבוע את הנתבעת), הליך שהסתיים בהסדר פשרה. בשלב זה סרבה הנתבעת להצטרף להסכם שנחתם ובהתאם לא נותרה בידי התובעת כל ברירה אלא לנקוט בהליך דנן. גם מו"מ שנוהל בין הצדדים לביצוע פרויקט תמ"א 38/2 לא צלח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 482/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור האמור עתרה התובעת למתן צוים לפיהם יהרסו הגדרות והבניה שביצעה הנתבעת בחצר הבית, יפוננו המטלטלין שהונחו, יהרסו המחסן וחדר הכביסה, יבוטל שער הכניסה מהחצר וינתן צו אשר ימנע מהנתבעת להגביל את זכות התובעת לעשות שימוש ברכוש המשותף.

5. הנתבעת טוענת כי התובעת, שרכשה את דירתה זה מקרוב (לפני כשלוש שנים), מבקשת לבטל הסכמות בנות 40 שנה הקיימות בבית - על פי הסדר זה (מפורש או מכללא) לכל אחד מבעלי הדירות זכות שימוש בלעדית בחלק מהחצר בבית ובהתאם נוהגים כל בעלי הדירות (לרבות אלו שאינם צד להליך זה) במשך השנים. אין בידי התובעת כל עילה לביטול ההסדר הקיים אשר גם היה ידוע לה עובר לרכישת הדירה על ידה, בין מכח ידיעת והסכמת הקודמים לה בזכויות ובין מכח העובדה כי החלוקה קיימת בפועל וברורה. גם הבניה בוצעה לפני שנים מכח אותה הסכמה עם חוכרים ובהתאם לזכויות על פי התקנון המוסכם. כל ההסדרים שבין התובעת לבעלי הדירות האחרים אין בהם לחייב את הנתבעת, ודאי כאשר יש בהם לפגוע בזכויותיה הקנייניות.

לאור ההסכמות הנהוגות במשך שנים כאמור טוענת הנתבעת כי יש לדחות את התביעה.

6. המחלוקת שבין הצדדים הינה, אם כן, האם ביד הנתבעת זכות חוקית לעשות שימוש בחצר הרשומה כרכוש המשותף ואם כן, מה מעמדה של זכות זו.

7. אעיר כי לא ממש ברורה טענת הנתבעת בסיכומיה בדבר העדר דפי פרוטוקול מתיק בית המשפט. דפי הפרוטוקול כוללים "מספר רץ" החל ממועד הדיון הראשון מיום 03.12.13 (עמודים 1-3), המשך במועד הדיון השני מיום 16.02.14 (עמוד 4) וכלה במועד דיון ההוכחות מיום 22.09.14 (עמודים 5-11). הפרוטוקול בכללותו מצוי בתיק ונמסר כדין ליד הנתבעת (בשני המועדים הראשונים באמצעות בא כוחה ובמועד השלישי ישירות לידה).

דיון והכרעה

הרקע המשפטי להכרעה

8. כבר נפסק בעבר כי הסכמת בעלי הדירות לשימוש ברכוש המשותף והקניית זכויות קנייניות איננה חייבת להינתן בכתב דווקא ואף הסכמה בעל פה בהקשר זה קבילה. הסכמה שכזו גם יכולה לחייב בעלי דירות אחרים שידעו על קיומה ונהגו על פי מציאות קיימת. הסכמה למתן רשות שימוש יכולה להילמד גם מכללא ומהתנהגות הצדדים לאורך שנים. אולם, בכדי ליתן תוקף קנייני להסכמה הרי שזו צריכה להיות מפורשת ולא ניתן ללמוד עליה במשתמע (ע"א 815/81 כליפא נ' שאול פ"ד לו(3) 78; ע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף (פורסם בנבו); ר' ע"א 9502/06 (מחוזי - י-ם) רונית לומברוזו נ' מיכאל קובנר (פורסם בנבו); ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פד"י לא(3) 210).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 482/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

9. על מנת להסיק ויתור מהתנהגות הרי שזו חייבת להיות "ברורה וחד משמעית, ולהעיד על גמירות דעת, ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר" (ע"א 7388/97 עיזבון משה זמיר ז"ל נ' יעל דולב (שמיר) (פורסם בנבו)).

10. משעה שניתנה ההסכמה, אין להתיר לבעל דירה שהסכים להתנער מהסכמתו או לחזור בו ממנה כאשר קיימים של מניעות מטעמי צדק (פרשת כליפא לעיל וכן ע"א 19/81 ביבי נ' הוברט פ"ד (2) 497; ע"א 31/70 כהן נ' שמאי פד"י כ(2) 388).

11. במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושבהם, בהסתמך על מתן הרישיון, נוצרה צפייה לגיטימית אצל בעל הרישיון כי הרשות ניתנה לצמיחות, אפשר ושיקולי הצדק יביאו להכרה ברשות השימוש כבלתי ניתנת לביטול, אף בהעדר הסכמה מפורשת מצד בעל הקניין (ר': ע"א 32/77 הנ"ל; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם בנבו),

12. שיקולי הצדק בהקשר זה יתבססו, בין היתר, על בחינת כוונת הצדדים בעת יצירת הרישיון, תנאי הרישיון, משך זמן ההחזקה ללא התנגדות והשקעות שהשקיע בעל הרישיון בנכס (היקפן, טיבן והסכמת בעל הזכויות לביצוען) (ר' עמ"ש 14-01-37005 פלוני נ' פלוני (פורסם בנבו) והאזכורים שם).

13. תום הלב של הצדדים מהווה גם הוא רכיב נדרש בבחינת שיקולי הצדק.

את ההלכה שנפסקה בע"א 810/82 זול בו בע"מ נגד זיידה ואח' פ"ד ל"ז (4) 737, ניתן להחילה גם על יחסים שבין בעלי דירות בבית משותף, כדברי כב' השופט ברק (כתוארו אז) שם (בעמ' 740): "בעלותו של שותף במקרקעין אין בה כשלעצמה "כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר" (סעיף 14 לחוק המקרקעין). הסייג השני קובע, כי הן הרוב והן המיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום לב (סעיפים 39 ו-61 (ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. המיעוט והרוב אינם זרים זה לזה. עבותות של קניין מקשרים ביניהם. חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם כוחות כלפי רעהו. בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג בהגינות". כך גם פוסק כב' השופט ח. כהן פסק בע"א 782/70 רדומילסקי נגד פרידמן פ"ד כה (2) 523 בעמ' 530: "ובא הכלל הגדול שבסעיף 14 לחוק וקובע שזכות הבעלות כשלעצמה אין בה כדי להצדיק עשיית כל דבר, ומתן צו-מניעה בכלל זה, "הגורם נזק או אי-נוחות לאחר" - רוצה לומר, אין להתיר את השימוש בזכות הבעלות כעילה לגרום נזק או אי-נוחות אפילו למסיג-גבול, מקום שהשימוש בעילה זו אינו דרוש באורח סביר למימוש זכות הבעלות עצמה או למטרה חוקית אחרת" (ההדגשה שלי, א.ס.). (ר' גם ע"א 8661/10 יוסף נעמה נ' תמר טורקיה (פורסם בנבו)). כב' השופט חשין ברע"א 7112/93 צודלר ואח' נ. ש. יוסף ואח' פ"ד מח (5) 550, החיל במפורש את עיקרון "תום לב" על



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 482/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף (ור' גם רע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נגד משה סלומון ואח' פד"י נה (1) 199).

האם בידי הנתבעת זכות קניינית?

14. הכלל הבסיסי הוא כי נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") והוא מוטל על שכמו של התובע בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה" (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי – קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333).

15. לאור מסמכי רישום הבית המשותף, שאינם שנויים במחלוקת, לפיהם אין החצר צמודה לדירת הנתבעת ולא מוקנות בתקנון כל זכויות שימוש ייחודיות, ולאור העובדה כי, למעשה, אין בין הצדדים מחלוקת כי הנתבעת עושה שימוש ייחודי ברכוש המשותף ואף ביצעה בנייה בו, הרי שדי בכך כדי להעביר לכתף הנתבעת את נטל ההוכחה כי בידה זכות קניינית לעשות שימוש בחצר, ולשיטתה, הסכם (ר' רע"א 296/11 מוחמד נג'אר נ' שאוקי חמדאן עליאן (פורסם בנבו)). דא עקא, לא עלה בידי הנתבעת להוכיח כי בידה זכות קניינית לשימוש בחצר.

16. ראשית, כאמור, מסמכי רישום הבית המשותף אינם מקנים לה זכות שכזו וגם אין כל תיעוד אחר בפנקסי המקרקעין בדבר קיומה של הסכמה כאמור.

17. שנית, גם לא עלה בידי הנתבעת לעמוד בנטל הנדרש להוכיח קיומה של הסכמה קניינית מפורשת לשימוש ברכוש המשותף. בהקשר זה לא צורפה כל הסכמה בכתב ואין כל תיעוד בכתב לאמור, כפי שגם עלה מהחקירה הנגדית (עמוד 8 שורות 9-11). עוד עלה מהחקירה הנגדית כי, למעשה, אין בידי הנתבעת כל ידיעה אישית בנוגע לקיומה של הסכמה מפורשת כאמור (עמוד 7 שורות 21-23 ועמוד 8 שורות 14-15). ויודגש, אין כל מסמך המגבש זכות כאמור.

18. שלישית, הנתבעת לא פעלה, משך 40 שנים, להסדרה קניינית בכל דרך של זכויותיה הנטענות (עמוד 8 שורה 12) אלא רק לאחר תחילתם של ההליכים דנן וללא קשר לקיומה של הסכמה קניינית קודמת (ר' מוצג ת/1).

האם בידי הנתבעת רשות שימוש?

19. במכלול הראיות שהוצגו בפני הוכחה על ידי הנתבעת קיומה של הסכמה של בעלי הדירות לשימוש ברכוש המשותף.

20. ראשית, עדותה של הנתבעת נותרה כעדות יחידה בכל הקשור למצבו של הבית והחצר, שימושים בו במשך 40 שנה והסכמות בעלי הזכויות בבית. הוכח כי בעת כניסת הנתבעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 482/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ובעלה לגור הדירה בשנת 1974 הגדר התוחמת (כפי שהיא כיום) כבר היתה קיימת וכך גם חלוקת החצר לשימוש ייחודי של בעלי הדירות השונות. גדר זו נהרסה ונבנתה מחדש בשיתוף פעולה, וברי כי בהסכמה, עם בעלי הזכויות בדירה נוספת בבית (עמוד 7 שורות 15-20). גם הבניה בוצעה ביחד עם בעלי דירה נוספת בבית ובהסכמת בעלי הדירות האחרים (עמוד 8 שורה 25). הוכח כי חלוקת החצר היתה מוסכמת על כל בעלי הדירות בבית שנהגו לפיה משך כל השנים, ובכלל האמור, לא נכנסו איש לחצרו של האחר (עמוד 8 שורות 8 ו-12-13).

21. בהקשר זה יוער כי מטעמה של התובעת הוגש אך תצהיר עדות ראשית חתום על ידה. ברי כי כל הקשור לפני שנת 2009, מועד רכישת הדירה על ידה, אינו יכול להיות מצוי בידיעתה האישית, ודאי כל הקשור למצבו של הבית ושימושים בו משך 40 שנה.

22. שנית, נספחים 2 ו-3 לתצהיר התובעת, מסמכי רישוי, מלמדים גם הם על קיומה של הסכמה בין בעלי הדירות. ראשית, חתימתם של בעלי הדירות מופיעה על גבי הבקשה להיתר בנספח 2. שנית, התחייבות בעלה של התובעת בנספח 3 מלמדת על כי עובר לבניה, כעדות הנתבעת, היו קיימים גדרות, שבילים ומדרגות בחצר הגובלת עם דירתה. לאור חתימת בעלי הדירות על הסכמתם לבניה ברי כי לא היו להם כל הסתייגויות גם בהקשר זה.

23. שלישית, התובעת הינה היחידה מבין בעלי הדירות בבית אשר נקטה בהליך דנן. אף לא אחד מבעלי הדירות האחרים בבית, אשר היו צד ישיר (או מכח ירושה) להסכמות ההסטוריות שבין הצדדים (עמוד 8 שורות 6-7), בחר להצטרף להליך האמור או לנקוט בהליך או אפילו לפנות בדרישה או בקשה כלשהי משך כל 40 השנים (עמוד 9 שורות 13-14). למעשה, לא הוצגה בפני כל טענה מצד בעלי הזכויות המקוריים או יורשיהם לביטול ההסכמות ההסטוריות או התנגדות (אפילו עכשוית) לחלוקה והשימוש בפועל כפי שמבוצעים ובוצעו במשך כל השנים.

24. אף אם אותם בעלי זכויות נוספים לא הצטרפו כתובעים להליך, הרי שלכל הפחות היה על התובעת להביאם לעדות מטעמה בכדי לתמוך את טענתה בדבר אי קיומה של הסכמה היסטורית או בדבר ביטולה על ידם. דא עקא, אף שמדובר בעדים זמינים (ולא הוצג כל טעם מדוע לא יכולה היתה התובעת להביאם לעדות בפניי) ולכאורה בעלי אינטרס משותף עם התובעת (לאור הסכם הפרשה ופסק הדין בתיק 332/11 כמפורט בסעיף 11 לתצהיר התובעת) הם לא הובאו לעדות בפניי.

25. ההלכה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736, 760



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 482/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651. בנסיבות דנן ניתן להסיק כי עדותם של בעלי הדירות האחרים היתה תומכת בגרסת הנתבעת בדבר קיומה של הסכמה היסטורית ותקפותה של הסכמה זו.

26. יוער כי במסגרת תיק בקשה ב"ב 620/13 עתרה הנתבעת לצירופם של בעלי הדירות האחרים בבית כנתבעים נוספים בהליך אך התובעת **התנגדה** לבקשתה זו. אציין כי בהחלטתי מיום 30.12.13 הבהרתי כי עמדתם של אותם בעלי דירות יכולה להישמע במסגרת מסכת הראיות "על פי זימונם מטעם מי מהצדדים". הנתבעת אכן זימנה את בעלי הדירות למתן עדות מטעמה ובחזרה לבסוף לוותר על עדותם שלא נדרשה לצורך הגנתה (עמוד 10 שורה 30). דא עקא, על אף האמור התובעת לא עמדה על העדתם של בעלי הדירות למרות חשיבות עדותם כאמור להוכחת גרסתה וכאשר, למעשה, אין בידה כל עדות קבילה הנוגדת את גרסת הנתבעת בנוגע ל"היסטוריה" בבית.

27. רביעית, בפרט אמורים הדברים כאמור כאשר בעלי הזכויות הנוספים בבית עשו ועושים גם הם שימוש ברכוש המשותף בהתאם לאותן הסכמות היסטוריות (שהרי זו היתה עילת תביעתה של התובעת כנגדם במסגרת ההליך בתיק 332/11).

28. חמישית, אומנם, אין בעדותה של הנתבעת לבסס קיומה של הסכמה מפורשת לבניית המחסן וחדר הכביסה. אולם, העובדה כי מדובר בבנייה ניכרת לעין, אשר בוצעה לפני שנים ובתחום שטח החצר לגביו קיימת הסכמה היסטורית לשימוש ייחודי כאמור, מלמדת על קיומה של הסכמה מכללא של בעלי הדירות גם לבנייה האמורה. ויוזכר, גם בעלי דירות אחרים ביצעו בניה דומה בחצר (ר' נספח 2 לתצהיר הנתבעת). יש לזכור כי גם התקנון המוסכם מקנה זכות בניה (אף שלגבי הרכיבים האמורים לא הוכיחה הנתבעת התקיימות התנאים הנדרשים בתקנון).

מה טיבה של רשות השימוש?

29. שיקולי הצדק ותום הלב בנסיבות דנן מחייבים הקביעה כי מדובר ברשות שימוש בלתי הדירה אשר התובעת איננה רשאית להביא לביטולה. אומנם, קביעה כאמור יש לעשות במשנה זהירות. אולם, הצטברות שיקולי הצדק ותום הלב מטים בכירור את המאזניים לטובת קביעה כאמור.

30. ראשית, מדובר ברשות שימוש ייחודית הנמשכת לאורך 40 שנה.

31. שנית, מדובר ברשות שימוש שמעולם לא בוטלה על ידי בעלי הזכויות המקוריים או חליפיהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 482/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

32. שלישית, שימוש דומה עודנו מבוצע גם על ידי בעלי הזכויות האחרים על פי אותה רשות שימוש (ר' נספחים 2 ו-3 לתצהיר הנתבעת). ניתן, למעשה, לראות בשימוש מקביל זה בגדר תמורה הדדית, ודאי כאשר גם בוצעה בניה על ידי בעלי הדירות.

33. רביעית, מדובר בשימוש הנגלה לעין בנקל, הן לעניין השימוש בחצר (לרבות גידורה) והן לעניין בניית מחסן וחדר הכביסה (ר' נספח ד לכתב התביעה). אף על פי כן לא הועלתה כל טענה או התנגדות משך עשרות שנים.

34. חמישית, מעדות הנתבעת ומן התמונות שצורפו ניכר כי בוצעו השקעות של הנתבעת ובעלה בטיפול והחזקת החצר, ודאי כאשר לא נסתרה העדות המוזכרת לעיל לפיה חלק מהעבודות בוצעו בשיתוף פעולה עם בעלי הדירות האחרים בבית. כאמור בוצעה על ידי הנתבעת גם בניה בפועל של מחסן וחדר כביסה בשטח זה.

35. שישית, לא עלה בידי התובעת להראות שינוי נסיבות כלשהו אשר המצדיק חזרה מההסכמה. בהקשר זה רצונה של התובעת להביא לחלוקה קניינית של הרכוש המשותף בבית וביצוע בניה אינם בגדר שינוי נסיבות מספיק. ודאי כאשר מדובר בבעלות זכויות אשר באה, זה מקרוב (בשנת 2009), לבית בו המצב נוהג משך שנים רבות. ויודגש, בעלי הדירות האחרים בבית אינם צד להליך זה ואינם חוזרים בהם באופן מפורש מן ההסכמות ההיסטוריות.

36. שביעית, התובעת ידעה על השימושים המבוצעים על ידי הנתבעת עובר לרכישת הדירה או למצער יכולה או צריכה היתה לדעת עליהם. כך עולה הדבר מעדותה בדבר התאמת המצב כיום בחצר למצב עובר לרכישת הזכויות על ידה (עמוד 5 שורה 14-15). כך גם עולה הדבר מעדותה בנוגע לפגישתה עם הנתבעת עובר לרכישת הדירה - "לא אמרתי לה למה השתלטת על החצר היא אמרה לי שהיא רוצה שיהיה הסכם שהשטח שלה ירשם בטאבו שלדעתה מר חגה לא יחתום לי על אפשרות בנייה אז אמרתי לה אני מוכנה שנגיע לכל הסכם שהוא" (עמוד 6 שורות 11-13). מדובר גם בשימוש נגלה לעין וברור.

37. לא סבירה בעיני טענת התובעת כי במהלך מספר פגישות שבין התובעת לנתבעת, לרבות בנוכחות עו"ד גולני, לא הזכירה כלל הנתבעת את השימושים המבוצעים על ידה ברכוש המשותף על פי ההסכמות ההיסטוריות (עמוד 6 שורה 4).

38. מכל מקום, אין בידי לקבל את עדותה של התובעת לפיה רכשה את הדירה לאור הצהרה מפורשת של המוכר כי מדובר בפלישה של הנתבעת לחצר וכי "אין שום הסכם" (עמוד 5 שורות 16-17) - ראשית, עדותה, כשלעצמה, הינה עדות שמועה. שנית, טענה זו לא נזכרה במפורש בתצהיר העדות הראשית ל התובעת. שלישית, אין בהסכם הרכישה (נספח 1 לתצהיר התובעת) אזכור בדבר קיומה של פלישה נטענת (אם אכן כך הצהיר המוכר בפני התובעת).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 482/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת בחרה, מסיבותיה שלה, שלא להביא לעדות בפני את מר ארד ממנו רכשה את הזכויות בדירתה וגם לא את עו"ד גולני, וללא כל הסבר. לאור ההלכות המוזכרות לעיל ניתן להסיק מסקנה כי גם עדותו של מר ארד היתה תומכת בגרסת התובעת לפיה היתה קיימת הסכמה היסטורית לחלוקת השימוש, אשר גם התובעת ידעה עליה עוד בטרם רכשה הזכויות בדירתה. כך גם ניתן להסיק מאי העדתו של עו"ד גולני. בהקשר זה טענות בדבר אי גילוי קיומה של הסכמה ושימוש בפועל לאורך שנים עליה להפנות כלפי מוכר דירתה ולא כלפי התובעת.

39. שמינית, למעשה, אין בשימוש המבוצע כל הפרעה אמיתית לתובעת וגם אין כל טענה לכך, למעט עמידה על זכותה הקניינית הרשומה (עמוד 6 שורה 20). זאת ועוד. כל מטרתה של התובעת היא להביא לחלוקה של הרכוש המשותף לשם הרחבה של דירתה, שהרי לכאורה גם במסגרת ההסכם המוצע יוצמדו החלקים האמורים לדירת נתבעת (ר' סעיף 30 לתצהיר התובעת). ויודגש, גם השימוש בפועל של בעלי הזכויות האחרים בבית על פי ההסכמות ההיסטוריות הותר קניינית במסגרת ההסכם (ר' נספח ב' לכתב התביעה).

למעשה, התובעת מאשרת ומסכימה לכל ההסכמות ההיסטוריות ובלבד שינתנו לה זכויות משותפות בהן היא חפצה. יש בהתנהלות התובעת כאמור משום חוסר תום לב.

הסכם הפשרה

40. הצדדים התייחסו בטיעוניהם גם למשמעותו של הסכם הפשרה בתיק 332/11 ואף שהדיון בהקשר זה איננו נדרש לצורך ההכרעה בהליך, בפרט כאשר אין כל זכר לטיעוני הגנה בהקשר זה במסגרת כתב ההגנה, אני מוצא לנכון להעיר מספר הערות בעניינו.

41. ראשית, הסכם הפשרה מסדיר, חוזית, את מערכת היחסים שבין הצדדים לו בלבד. כשם שאין בו לחייב את התובעת בחיובים על פיו להם היא מתנגדת (הענקת זכויות בלעדיות, הגדרת חלקים מסויימים כרכוש משותף, חלוקת זכויות בניה, פטור מתשלום דמי איזון), אין בו גם לזכות אותה בזכויות על פיו.

42. לדידי אין מדובר גם בחוזה לטובת צד שלישי כנטען על ידי התובעת (ר' בהקשר זה למשל ה"וואיל" 8-10 במבוא להסכם וכן סעיפים 35 ו-36). מכל מקום סוגיה זו מצוייה, על פי תביעה שהגישה התובעת, להכרעה בפני ערכאה אחרת (ר' מוצג ת/1) ואין בה להוות טענת הגנה בהליך דנן.

43. שנית, מבחינה ראייתית הסכם הפשרה מחזק את הקביעות בפסק דין זה. כאמור, לא נעשתה הסכמה קניינית היסטורית בין הצדדים לחלוקת הרכוש המשותף בבית ובהתאם גם הצהרת הצדדים בסעיף 36 להסכם. מאידך, אין בהסכם זה כל התייחסות לקיומו של שימוש דה פאקטו ברכוש המשותף לאורך שנים וברשות השימוש ההיסטורית. אין גם ביטול של רשות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 482/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שימוש זו, ודאי שלא ביטול מפורש (אף אם הצדדים, בינם לבין עצמם, מגדירים לכאורה חלק מהרכוש כ"רכוש משותף").

44. שלישית, כאמור לעיל, שעה שהסכם הפרשה מקנה לנתבעת (ולבעלי הדירות האחרים) את אותן הזכויות על פי ההסכמות ההיסטוריות, הרי שברור כי המטרה האמיתית של הליך זה היא לכפות על הנתבעת לחתום גם היא על ההסכם האמור בניגוד לרצונה. ההסכם מחזק את הטענה כי אין המדובר כאן בעמידה של התובעת על זכויותיה הקנייניות בתום לב.

סיכום

45. לאור כל האמור לעיל אני קובע כלהלן:

46. לנתבעת זכות שימוש בלתי הדירה בחצר ובכלל האמור בחדר הכביסה ובמחסן ולפיכך התביעה נדחית.

47. ויודגש, לא הוכרה קיומה של זכות קניינית לנתבעת לשימוש כאמור.

48. התובעת תשלם לנתבעת בגין החזר הוצאות ניהול ההליך סך של 2,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

49. בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתנהלו בתיק זה שלושה דיונים, הוגשו תצהירים וסיכומים בכתב. מאידך, התחשבתי בהתנהלות הצדדים בתיק זה, בכך שבקשה לסילוק על הסף מטעם הנתבעת נדחתה ובכך שבחלק ארי ומשמעותי של ההליך הנתבעת כלל לא היתה מיוצגת.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"א טבת תשע"ה, 12 ינואר 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב